

1516895-88.2022.8.26.0228

Classe: Inquérito Policial

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: SIMONE CANDIDA LUCAS MARCONDES

Comarca: SÃO PAULO

Foro: Foro Central Criminal Barra Funda

Vara: 17ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 18/10/2022

... - Assunto:

Inquérito Policial - Tráfico de Drogas e Condutas Afins (COVID-19)

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante - 2203519/2022 - 06º DELEGACIA DA DISE - DENARC, 26383886 - 06º DELEGACIA DA DISE - DENARC, 2203519 - 06º DELEGACIA DA DISE - DENARC

Autor:

Justiça ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA DE SÃO PAULO

Foro Central Criminal Barra Funda

17ª Vara Criminal

Av. Abrahão Ribeiro, 313, São Paulo-SP - cep 01133-020

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às17h00min

1516895-88.2022.8.26.0228 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1516895-88.2022.8.26.0228

Classe - Assunto:

Inquérito Policial - Tráfico de Drogas e Condutas Afins (COVID-19)

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante - 2203519/2022 - 06º DELEGACIA DA DISE - DENARC, 26383886 - 06º DELEGACIA DA DISE - DENARC, 2203519 - 06º DELEGACIA DA DISE - DENARC

Autor:

Justiça Pública

Indiciado:

FERNANDO DA GAMA SOUZA JUNIOR e outro

Juiz(a) de Direito: Dr(a). SIMONE CANDIDA LUCAS MARCONDES

Vistos.

ELVIS TORRES FONSECA DE ANDRADE E FERNANDO DA GAMA SOUZA JÚNIOR, com qualificação nos autos, foram denunciados como incurso no art. 33, caput, da Lei nº 11.343/06 na forma do artigo 29 do Código penal, porque, no dia 27 de julho de 2022, na Avenida Duque de Caxias, 75, República, nesta cidade e Comarca de São Paulo/Capital, Elvis Torres Fonseca De Andrade E Fernando Da Gama Souza Júnior, qualificados, respectivamente a fls. 04/05, receberam, portaram, traziam consigo e transportavam, para entrega e comercialização a terceiros pessoas, substâncias entorpecentes causadoras de dependência química e psíquica, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar. Auto de exibição e apreensão de

fls. 11 e laudo de constatação de fls. 14/17. Laudo químico toxicológico definitivo a ser oportunamente juntado.

Consta da denúncia que guardas civis metropolitanos realizavam patrulha de rotina na via de acesso à aglomeração de dependentes químicos frequentadores de notório ponto de venda de drogas conhecido como "cracolândia", quando avistaram os denunciados em típica conduta de venda de entorpecentes, entregavam a droga a transeuntes e deles recebiam dinheiro em pagamento. Assim que os denunciados perceberam a presença dos guardas civis municipais, ambos empreenderam fuga, todavia, perseguidos pela equipe, foram detidos, sendo certo que em revista pessoal foi encontrado parte do entorpecente apreendido com cada um deles.

Com Elvis e Fernando foram localizadas 01 (uma) pedra de crack com peso de 85,3 gramas, 01 (uma) pedra de crack com peso de 64,3 gramas e diversos fragmentos de pedra de crack com peso bruto de 9,8 gramas (laudo de constatação de fls. 14/17). Ambos, informalmente, confessaram a traficância sendo certo que ELVIS, ainda informou que durante o trajeto de fuga, dispensara sacola contendo mais drogas e dinheiro, não sabendo precisar quantidade e valores lá contidos. Em varredura pelo local os guardas civis municipais não localizaram a sacola dispensada.

Formalmente interrogados, perante a digna Autoridade Policial, os denunciados preferiram quedar-se silentes.

Os réus foram citados (fls. 215/216). Apresentaram Defesa Prévia (fls.169/174).

Recebida a denúncia, em audiência de instrução, debates e julgamento foram ouvidas duas testemunhas. O réu Elvis foi ao final interrogado. O réu Fernando apesar de intimado não compareceu, sendo decretada sua revelia. As partes debateram.

O Ministério Público requereu a procedência da ação, nos termos da denúncia.

A Defesa requereu a nulidade da revista efetuada por guardas civis, a absolvição do acusado Fernando e, subsidiariamente requer-se: a) desclassificação para uso, eis que a quantidade de entorpecente supostamente apreendida em poder do acusado é ínfima, compatível com o uso. No mais, trata-se da cracolândia, local conhecido por ser frequentado por usuários. Os guardas disseram que viram os acusados entregarem algo para umas pessoas, porém não viu receberem nada em troca. Não viram o que era. Nenhuma quantidade de dinheiro foi apreendida em poder dos acusados, a demonstrar que não são traficantes; b) fixação da pena-base no mínimo legal, sendo o réu primário; c) reconhecimento e aplicação da causa de diminuição de pena prevista no art. 33, §4º, no patamar máximo, eis que presentes todos os requisitos para tanto, em especial considerando a primariedade do acusado; d) fixação de regime inicial aberto; e) substituição por pena restritiva de direito; f) direito de recorrer em liberdade.

É o relatório do necessário.

FUNDAMENTO E DECIDO.

Preliminarmente, afasto a alegação de nulidade pleiteada pela Defesa.

Trata-se de preliminar aventada pela defesa, alegando que a prisão flagrancial do acusado prisão em flagrante do acusado e a apreensão dos entorpecentes ocorreram por meio de atuação ostensiva de guardas civis. Aduz, em síntese, que a diligência teria extrapolado os limites da atribuição constitucional dentro da qual não estariam previstos os poderes típicos da Polícia Judiciária ou mesmo da Polícia ostensiva.

Ressalto que os Guardas civis metropolitanos, em exercício de policiamento preventivo, detinham competência para proceder à abordagem e prisão em flagrante. Não se deve olvidar que, de fato, as atribuições da Guarda Civil Metropolitana estão constitucionalmente previstas, não se confundindo com aquelas fixadas para os demais órgãos policiais. De qualquer modo, todas integram o vasto campo da segurança pública, a qual, conforme prevista pelo legislador constituinte, caracteriza-se, nos termos do art. 144, §10: "pela preservação da ordem pública e da incolumidade das pessoas e do patrimônio".

Contudo, no caso particular dos guardas civis, o constituinte foi mais restrito, circunscrevendo a atuação à proteção dos bens, serviços e instalações do município, o que, obviamente, não inclui as ações próprias da Polícia Federal (art. 144, § 1º), da Polícia Civil dos Estados (art. 144, § 4º) ou mesmo da Militar (art. 144, § 5º).

É, contudo, o mesmo texto constitucional que prevê a hipótese da prisão em flagrante como figura excepcional à exigência de prévia ordem judicial para a restrição da liberdade. A exceção, repise-se, é justificada em face das circunstâncias extremas que cercam a situação flagrancial e que são representadas pelos requisitos da atualidade e imediatidade.

Ou seja, naquelas hipóteses, o Estado está autorizado a recompor, prontamente, a ordem pública mediante a detenção urgente e temporária do suposto autor, até decisão judicial ulterior. Trata-se, repita-se, de providência urgente reveladora da supremacia que o valor segurança pública merece frente ao valor da liberdade, na hipótese de flagrante delito.

Não são outras as razões que levaram o legislador infraconstitucional a impor o dever, às autoridades policiais e aos seus agentes, de efetuarem a prisão em flagrante, facultando-a a qualquer do povo. Destarte, ainda que não seja possível subsumir-se a figura do guarda civil às hipóteses dadas pelo artigo 301 do Código de Processo Penal, restar-lhe-ia o poder que é outorgado a qualquer do povo. Trata-se, note-se, de poder de graves consequências, o qual implica restrição da liberdade de locomoção. Logo, não soa razoável, para dizer o mínimo, estivessem todos investidos do poder de restrição de um dos mais importantes e valiosos direitos liberdade sem que tal fosse acompanhado de outros poderes implícitos, como é o caso da busca pessoal.

Obviamente, tal conclusão há de ser tomada com ponderação, evitando-se uma ampliação indevida dos poderes restritivos dos direitos fundamentais. Não é o risco desenhado pelo caso dos autos.

Com efeito, conforme apontam os elementos probatórios, guardas municipais realizavam patrulhamento pelo local dos fatos, a região conhecida por altos índices de delinquência, quando avistaram os réus em atitude típica de venda de drogas, eis que entregavam algo a terceiros e havia ali muitos usuários de drogas, já que era a região da cracolândia e, ao notarem a aproximação dos guardas civis, os réus tentaram fugir, contudo os guardas conseguiram detê-los.

Realizada a busca pessoal, encontraram nas vestes dos acusados as drogas apreendidas (pedras de crack).

Havia, portanto, elementos visuais que suscitavam fundadas suspeitas de que os acusados estivessem na posse de objetos ilícitos. Afinal, estava no maior ponto de tráfico de drogas da capital de São Paulo e, mesmo estando em meio a outros usuários que perambulam pelo local, se destacaram pelo comportamento típico de mercancia.

Ou seja, a busca pessoal foi realizada no contexto da abordagem e da prisão, em local de grande periculosidade, de modo que não seria razoável exigir-se o aguardo da chegada dos policiais militares para, somente então, proceder-se à busca.

A urgência e os riscos existentes autorizavam a medida que, portanto, mostrou-se razoável.

Nesse sentido, já se decidiu:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS. CONDENAÇÃO RATIFICADA EM GRAU DE APELAÇÃO. PRISÃO EM FLAGRANTE REALIZADA PELA GUARDA MUNICIPAL. ALEGAÇÃO DE PROVA ILÍCITA. INOCORRÊNCIA. CRIME PERMANENTE. ART. 301 DO CPP. PRECEDENTES. AGRAVO IMPROVIDO. 1. Apesar das atribuições previstas no art. 144, § 8º, da Constituição Federal, se qualquer pessoa do povo pode prender quem quer que esteja em situação de flagrância, não se pode proibir o guarda municipal de efetuar tal prisão (HC 286.546/SP, Rel. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, Sexta Turma, julgado em 22/9/2015, DJe de 15/10/2015). 2. Nesse aspecto, o Superior Tribunal de Justiça possui jurisprudência no sentido de que inexistente irregularidade na prisão em flagrante promovida por guardas municipais, estando suas condutas amparadas pelo art. 301 do Código de Processo Penal, segundo o qual qualquer do povo poderá e as autoridades policiais e seus agentes deverão prender quem quer que seja encontrado em flagrante delito, como ocorreu na hipótese dos autos. STJ, AgRg no HC 592.722/SP, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 20/10/2020, DJe 26/10/2020).

HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO. INADMISSIBILIDADE. TRÁFICO DE DROGAS. PRISÃO EM FLAGRANTE. GUARDA MUNICIPAL. NULIDADE DA SENTENÇA E DO ACÓRDÃO. NÃO OCORRÊNCIA.

BUSCA PESSOAL E DOMICILIAR. PROVA ILÍCITA. INEXISTÊNCIA. CRIME PERMANENTE. PARECER ACOLHIDO. (...) 2. Na hipótese dos autos, não há falar em nulidade da sentença e do acórdão sob a alegação de irregularidade na prisão em flagrante, visto que os integrantes da Guarda Municipal flagraram o paciente, em via pública, na posse de entorpecentes destinados à mercancia, estando suas condutas amparadas pelo art. 301 do Código de Processo Penal, segundo o qual qualquer do povo poderá e as autoridades policiais e seus agentes deverão prender quem quer que seja encontrado em flagrante delito. 3. Apesar das atribuições previstas no art. 144, § 8º, da Constituição Federal, se qualquer pessoa do povo pode prender quem quer que esteja em situação de flagrância, não se pode proibir o guarda municipal de efetuar tal prisão. 4. Em razão do caráter permanente do tráfico de drogas, cuja consumação se prolonga no tempo, a revista pessoal ou domiciliar que ocasionou a prisão em flagrante, não representa prova ilícita (Precedente). (STJ-HC 286.546/SP, Rel. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, SEXTA TURMA, julgado em 22/09/2015, DJe 15/10/2015) (grifos nossos)

Ressalto, por fim, que na hipótese dos autos, os guardas municipais estavam em operação de segurança à zeladoria da prefeitura, que iria fazer a limpeza do local, quando se depararam com os réus, nada havendo que macular, portanto, a sua atuação. No mérito, a ação é procedente. Ao final da instrução, restaram comprovados os fatos descritos na denúncia.

Demonstrou-se a materialidade do delito pelo auto de prisão em flagrante (fl.01), boletim de ocorrência (fls.06/08), auto de exibição e apreensão (fl.11), laudo de constatação (fls.14/17) e laudo químico toxicológico de fls. 139/141.

A autoria também é certa e indubitosa.

Interrogado, o réu Elvis negou o cometimento do crime. Disse que é usuário de crack. Os guardas empurraram a massa em seis viaturas para conduzi-los a outra via e na dispersão todos saíram correndo e houve dispersão de várias sacolas. Nisso pegou a sacola e continuou correndo, sem saber que havia drogas no seu interior. Tinham dois policiais atrás dele e estava em posse do pedaço de sacola que jogou dentro da calça. Não conhecia o Fernando. Não tem antecedentes criminais. É dependente químico.

O réu Fernando é revel e não compareceu em Juízo para dar sua versão dos fatos.

Em que pese a negativa do réu, a prova amealhada nos autos autoriza a condenação.

A Testemunha Franciele Cristina, guarda civil, afirmou que viram os réus juntos em local com vários usuários de drogas. Dava para ver que eles estavam passando alguma coisa para outras pessoas. Os dois correram quando foram ser abordados. Correram atrás deles e conseguiram alcança-los na Rua Guaianazes. Elvis falou que tinha dispensado uma sacola com drogas e dinheiro, porém não acharam a sacola. Na revista com Elvis tinha um pouco de crack. Estava dentro de um compartimento de plástico, alguns estilhaços e uma pedra. Com o Fernando seu outro colega quem capturou e também foi achada uma pequena quantidade de drogas. Não foi apreendido dinheiro. Viu nitidamente os dois passando o que parecia ser droga para um usuário.

A Testemunha Diego, Guarda Civil, disse que estavam protegendo agentes da prefeitura que fazem a zeladoria do local, e estavam próximo ao local de fluxo de usuários, quando avistaram os dois réus, há uns 10 metros de distância, distribuindo alguns objetos, e suspeitaram da mercancia. No momento que terminou a limpeza o fluxo deslocou e resolveram aborda-los, mas os dois empreenderam fuga e conseguiram aborda-los e na revista pessoal foram encontradas algumas pedrinhas de crack. Com os dois tinha crack. Tinha uma pedra grande e outras diversas pequenas já prontas para consumo. Deu para identificar muitos usuários se aproximando deles e eles passando alguma coisa. Um dos réus (Elvis) falou que tinha dispensado sacola com droga na via pública, mas não encontraram. Conseguiu abordar o Fernando e com o Elvis sua parceira encontrou crack também. Sempre estão no local em operação, pois fazem a segurança dos funcionários da limpeza da prefeitura. Não foi apreendido dinheiro. O Crack estava na cintura do Fernando. Ele portava uma quantidade menor de droga que Elvis. Os réus estavam há uns cinco metros de distancia um do outro, e não exatamente juntos. Só visualizaram entregando algo, mas não o usuário entregando dinheiro.

Os depoimentos dos agentes estatais guardam coerência entre si e com o relatado na

fase inquisitiva.

Os guardas civis que procederam à prisão em flagrante do réu fizeram relatos uníssonos e detalhados, confirmando os depoimentos prestados na fase policial. Os depoimentos dos agentes estatais despontam sólidos e harmônicos, nada havendo nos autos a maculá-los de suspeitos, não sendo de todo crível que viessem a juízo incriminar falsamente pessoa inocente, eles que negaram conhecer o réu antes dos fatos, circunstância que foi confirmada pelo próprio acusado, que não apresentou em juízo, portanto, nenhum motivo para estar-se vendo injustamente acusado pelos mesmos guardas civis que efetuaram a sua prisão.

Anoto, por fim, que o fato de o réu ser usuário de drogas não afasta a possibilidade de atuar no tráfico de drogas, na venda de entorpecentes e, no caso em concreto, as circunstâncias da prisão, em especial a visualização de entrega de droga a terceiros e a fuga dos agentes estatais, aliado ao depoimento uníssonos dos agentes não deixam dúvidas que a droga se destinava ao comércio ilícito.

Certa, portanto, a condenação dos réus por infração ao artigo 33, caput, da Lei nº 11.343/2006.

Passo à DOSIMETRIA DA PENA.

Na primeira fase de dosimetria da pena, observando-se os elementos norteadores contidos nos artigos 59 e 60 do Código Penal e ainda o artigo 42 da Lei nº 11.343/2006, dada a natureza nociva das drogas - crack - encontradas em poder dos acusados, que serviria à venda, a revelar elevado e devastador efeito psicotrópico, dados seus efeitos nocivos à saúde pública e à sociedade, fixo a pena base acima do mínimo legal, fixando-a em 06 (seis) anos de reclusão e 600 (seiscentos) dias-multa.

Anoto que a jurisprudência vem na linha do entendimento do juízo, confira-se: "A natureza nociva da substância entorpecente apreendida - cocaína - constitui fundamentação idônea a ensejar maior apenação na primeira etapa da dosimetria, pela desfavorabilidade das consequências do delito." (HC 141092/MS).

Na segunda fase nada a considerar.

Na terceira fase da dosimetria da pena, em atenção ao artigo 33, §4º da Lei nº 11.343/2006, considerando a primariedade e bons antecedentes dos acusados e não havendo comprovação de que se dediquem a atividades criminosas ou integrem organização criminosa, reduzo as penas no máximo, estabelecendo-as em definitivo em 02 (dois) anos de reclusão e 200 (duzentos) dias-multa.

Considerando a primariedade dos acusados, bons antecedentes, além das circunstâncias do crime (pequena quantidade de drogas) e diante da quantidade de pena aplicada, substituo a pena privativa de liberdade por duas penas restritivas de direitos, consistentes em prestação pecuniária de ¼ do salário mínimo vigente à época de seu efetivo adimplemento, em favor entidade com destinação social a ser indicada pelo Juízo das Execuções; e prestação de serviços à comunidade, pelo mesmo período da pena substituída, à razão de uma hora de tarefa por dia de condenação, a entidade a ser definida pelo juízo das execuções criminais.

Ausentes elementos quanto à condição econômica do réu, estabeleço o valor do dia-multa no mínimo legal, em 1/30 do salário mínimo vigente ao tempo dos fatos.

Ante o exposto, julgo PROCEDENTE a presente ação penal para CONDENAR ELVIS TORRES FONSECA DE ANDRADE E FERNANDO DA GAMA SOUZA JÚNIOR, qualificados nos autos, como incurso no artigo 33, caput, da Lei nº 11.343/06 às penas de 02 (dois) anos de reclusão, além do pagamento de 200 (duzentos) dias-multa, no valor unitário mínimo, estabelecido o regime inicial aberto para início de cumprimento da pena e substituída a pena privativa de liberdade por duas penas restritivas de direitos, consistentes em prestação pecuniária de 1/4 salário mínimo vigente à época de seu efetivo adimplemento, em favor de entidade com destinação social; e prestação de serviços à comunidade, pelo mesmo período da pena substituída, à razão de uma hora de tarefa por dia de condenação, a entidade a ser definida pelo juízo das execuções criminais.

Tendo em vista a pena aplicada e o regime fixado (aberto), poderão apelar em liberdade.

Com o trânsito em julgado, lance-se o seu nome no rol dos culpados e expeça-se guia de recolhimento definitiva.

DECRETO, como efeito da sentença condenatória, a perda das quantias apreendidas em favor da União, a teor do disposto no art. 63 da Lei 11.343/06.
Oportunamente, expeça-se o necessário.
Custas na forma da lei.
P.R.I.C.

São Paulo, 18 de outubro de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA